

1005112-90.2021.8.26.0132

Classe: Ação Civil Pública

Assunto: Violação aos Princípios Administrativos

Magistrado: MARIA CLARA SCHMIDT DE FREITAS

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... oriundas dos disputados cargos, tais como tráfico de influência, situação de temor, represália ou esperança de tratamento privilegiado, implicando, com isso, em captação de clientes e causas. Dentro desse contexto, não bastasse o impedimento legal imposto pelo EAOAB (Lei 8.906/94), o exercício de "cargos ou funções de direção em órgãos da Administração Pública direta ou indireta, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Cível

Parque das Américas, 55

CEP: 15800-032 - Catanduva - SP

Telefone: (17) 3522-2299 - E-mail: catanduva2cv@tjsp.jus.br

1005112-90.2021.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1005112-90.2021.8.26.0132 - Ordem:

Classe - Assunto

Ação Civil Pública - Violação aos Princípios Administrativos

Requerente:

Justiça Pública

Requerido:

Prefeitura Municipal de Pindorama

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA CLARA SCHMIDT DE FREITAS:

C O N C L U S ã O:

Aos 15 de março de 2022, faço os presentes autos conclusos à Dra. MARIA CLARA SCHMIDT DE FREITAS, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível.

O Esc.

Vistos,

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER em face do MUNICÍPIO DE PINDORAMA alegando que município réu conta com dois cargos de Procuradores efetivos e concursados nos seus quadros, ocupado com apenas um, mas com a possibilidade de nomeação de outro, fato já objeto de duas ações civis públicas ajuizadas na Comarca, mas, mesmo assim, o Município está sempre a contratar escritórios de advocacia, o que já é objeto da ação n. 1008290- 81.2020.8.26.0132, ao invés de se valer do seu corpo técnico e concursado, fato também tratado nos autos da ação civil pública por improbidade n. 1008522- 93.2020.8.26.0132. Tem-se observado há algum tempo que o Município não privilegia seu corpo técnico de Procuradores concursados, não faz concurso para provimento de um dos cargos de Procurador, mas, no passado, já teve o quadro

completo, com dois Procuradores, o que poderia voltar a ter, situação que já poderia ter sido regularizada antes mesmo da pandemia, e tem colocado os seus Mui Dignos Secretários Jurídicos ou Secretários de Negócios Jurídicos para atuar como advogado do Município. Como são poucos processos de Pindorama nos quais o Ministério Público manifesta-se, acreditou-se que eram casos esparsos e esporádicos, mas a situação foi se avolumando no mandato da Prefeita anterior, continuando no atual mandato. Antes mesmo que a dúvida sobre a situação concreta pudesse ser consolidada, no inquérito civil que originou a ação civil pública n. 1008290- 81.2020.8.26.0132, inquérito civil n. 4.0718.0001219/2017, arquivado e homologado pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, restou recomendado que a Promotoria apurasse tal situação, constituindo em Respeitável Ordem Superior da qual não posso me distanciar e, portanto, preciso, tomar providências para a solução da questão, atendendo a Respeitável Recomendação do Egrégio Conselho Superior. Ademais, o Egrégio Conselho Superior chamou a atenção deste Promotor de Justiça para o Enunciado n. 35, da Egrégia Procuradoria Geral de Justiça, que pontifica: " 35: "CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. ADVOCACIA PÚBLICA As atividades da Advocacia Pública (assessoria e consultoria a entidades e órgãos da Administração Pública), inclusive sua Chefia, são reservadas a profissionais recrutados por concurso público". Visualizada a legislação local que trata da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e do cargo de Secretário Municipal dos Assuntos Jurídicos, Lei n. 2.104/2013, nos artigos 21 e 22 e Lei Complementar 2273/2017, no Anexo I , conclui-se que não há qualquer norma municipal autorizando, determinando, ordenando ou conferindo ao Secretário a atribuição de procuradoria do Município, ou seja, o Secretário Jurídico, em Pindorama, legalmente, não está autorizado a representar judicialmente o Município, o que, segundo a legislação municipal, que está correta e condizente com o melhor direito constitucional, somente os Procuradores e o Procurador Geral teriam referida atribuição, seja pelo teor da Lei n. 2.104/2013, artigos 21 e 22, seja pela Lei 2.410/2021, artigo 1º, funções Procurador Geral e Procurador Jurídico, que cuida das atribuições desses cargos, o que, anteriormente, era tratado no Decreto n. 2203/2014, o que foi corrigido pela lei de 2021 já mencionada. O cargo de Procurador Geral, inclusive, guarda uma peculiaridade, pois já foi considerado, na ADIN 2028175-28.2014.8.26.0000, inconstitucional e extinto, tendo sido, já, legalmente, extinto também pela Lei Municipal 2241/2017, considerando-se, portanto, as atribuições constantes na Lei Municipal n. 2.410/2021, que não criou cargos, mas apenas fixou legalmente as atribuições dos cargos que era tratada no Decreto 2203/2014, corrigindo essa situação, mas, portanto, sem restabelecer o cargo de Procurador Geral, o que significa dizer que qualquer menção ao cargo de Procurador Geral na legislação mencionada (Leis 2.104/2013 e 2273/2017) não pode ser aqui considerada, pois o cargo não existe e nem tem sido ocupado, informação obtida nos autos n. 1005088-62.2021.8.26.0132, o que permite concluir, estando a legislação municipal conforme a legislação, que apenas os Procuradores Jurídicos, cargos efetivos e concursados, podem exercer a advocacia no âmbito legislativo municipal. Assim, embora a Recomendação do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público traga o Enunciado n. 35, do Eminente Procurador Geral de Justiça para ser observado e investigado, não há qualquer razão para o envio do fato à análise de inconstitucionalidade, pois o cargo de Procurador Geral já não existe e porque na legislação de Pindorama está claro e cristalino que apenas os Procuradores Jurídicos, em número de dois, podem representar judicialmente o Município e possuem capacidade postulatória para exercer a representação processual do Município, não havendo necessidade de se declarar nada inconstitucional, pois legalmente está tudo conforme a constituição e a legislação. Entretanto, como afirmado, observando-se os processos de Pindorama, verifica-se que há algum tempo os Mui Dignos Secretários Jurídicos têm exercido a advocacia pelo Município, o que contraria a regra do exercício da Procuradoria Jurídica do Município exclusivamente por procurador servidor público concursado e efetivo. Mas, a questão é séria, mas não importa em improbidade administrativa, pois não parece que os Secretários Jurídicos, nem os Prefeitos tenham agido de má fé, com dolo, com intenção deliberada de fraudar o erário ou de infringir os princípios administrativos constitucionais. Mas, ofende

inclusive o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme redação dos artigos 27 e 28 inciso III do EAOAB (Lei 8.906/94). Além disso, especificamente em relação aos Procuradores Gerais, são eles legitimados “exclusivamente” para o exercício da advocacia vinculada à função pública que exerçam, conforme art. 29 da mesma lei. Não bastasse isso, aos ocupantes do primeiro escalão da estrutura administrativa do Município, Secretários Municipais, exige-se dedicação exclusiva em razão da natureza jurídica do cargo ocupado, quais sejam: - Livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo; - Transitoriedade; - Exercício de atividades fixadoras de metas, diretrizes e planos governamentais essenciais para a consecução dos objetivos públicos (direção, chefia e assessoramento); - Preenchimento por qualquer cidadão (interno ou externo à Administração Pública); - Desnecessidade de formação específica. O artigo 29 do Estatuto objetivando assegurar igualdade entre os advogados estabelece a incompatibilidade relativa ou impedimento genérico, significando que o exercício da advocacia está limitado exclusivamente às funções que exercem no cargo público. Tal restrição minimiza possíveis vantagens, em tese, oriundas dos disputados cargos, tais como tráfico de influência, situação de temor, represália ou esperança de tratamento privilegiado, implicando, com isso, em captação de clientes e causas. Dentro desse contexto, não bastasse o impedimento legal imposto pelo EAOAB (Lei 8.906/94), o exercício de “cargos ou funções de direção em órgãos da Administração Pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público”, concomitantemente com o exercício da advocacia, pode também constituir improbidade administrativa prevista no caput do art. 11 da Lei 8.429/92, conforme já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Requer a procedência dos pedidos da inicial para condenar o Município de Pindorama à obrigação de fazer consistente em cumprir sua própria legislação, passando toda a Procuradoria do Município, serviços jurídicos judiciais e extrajudiciais, aos Procuradores, servidores públicos concursados e efetivos, bem como à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de passar serviços jurídicos, representações processuais e trabalhos típicos da Procuradoria, previstos nos artigos 21 e 22, da Lei Complementar n. 2104/2013, ao Secretário Jurídico, sob pena de multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por processo no qual o Secretário Jurídico officie ou participe representando o Município, requerendo a apreciação deste pedido em tutela antecipada de urgência, com fulcro no artigo 300, do Código de Processo Civil, pela probabilidade do direito alegado e para evitar danos maiores pelo agravamento da situação ilegal, causando risco ao resultado útil do processo e condenar o Município réu, ao final da ação, ao pagamento das custas, emolumentos, encargos e demais despesas processuais, inclusive eventuais perícias requeridas no curso do processo. Protestou por provas e instruiu a inicial com documentos (fls. 01/274). Indeferido o pedido de tutela de urgência (fls. 275/278) que foi mantido pelo V. Acórdão de fls. 536/541.

Citado, o MUNICÍPIO DE PINDORAMA ofertou contestação alegando que ao contrário do mencionado pelo Ministério Público, a municipalidade, embora tenha por lei, dois cargos criados de procurador jurídico, atualmente conta com 01 (um) Procurador Jurídico concursado em exercício, e que possui carga horária de 20 (vinte) horas semanais, o qual atualmente é responsável exclusivamente pelos Processos de Execução Fiscal, os quais remontam mais de 7.000 mil processos em andamento. Muito embora não seja o mérito em questão, cumpre informar, que, com o advento da Lei Complementar 173/2020, os entes afetados pela calamidade pública estão impedidos de: Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares; V -

realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV. Muito embora existam dois cargos de Procurador na estrutura administrativa do município, sendo que apenas um se encontra provido, e, diante da vasta carga de serviços, que não diminuiu em razão da pandemia, além do que, há expressa permissão legal ao Secretário de Assuntos Jurídicos, para representar a municipalidade em juízo, como será demonstrado na presente manifestação. Por oportuno, resta claro que a municipalidade é quem sofrerá os prejuízos, caso o Secretário de Assuntos Jurídicos seja proibido de representar a Fazenda Municipal em juízo, em razão da vasta carga de serviços, que em momento algum foi minimizado em razão da pandemia. pela literalidade do texto legal, a realização de concursos e contratação de novos servidores está proibida em razão das medidas legais excepcionais decorrentes da pandemia, isto é, a requerida encontra-se impedida de realizar concurso público para preenchimento da vaga de procurador jurídico municipal, o que, frise-se, não iria suprir a enorme demanda da municipalidade. Ademais, no julgamento do Supremo Tribunal Federal STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AgR RE 0000040-55.2011.8.25.0056 SE - SERGIPE 0000040-55.2011.8.25.0056, restou consignado que os municípios não são obrigados a possuir Procuradorias Municipais em carreira, Ademais, a Administração Pública tem discricionariedade, podendo escolher qual será a forma de gerir sua área jurídica. Tanto pode contratar advogados (escritórios de advocacia), através de processo licitatório, como criar procuradorias municipais. o município de Pindorama/SP, conta hoje com apenas um procurador jurídico municipal, e que possui carga horária de 20 (vinte) horas semanais, o qual atualmente é responsável exclusivamente pelos Processos de Execução Fiscal, os quais remontam mais de 7.000 mil processos em andamento. O Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, que esta subscreve, atualmente é responsável por todo expediente administrativo, por volta de 150 (cento e cinquenta) processos mensais para emissão de parecer, além de Assessorar Juridicamente o Chefe do Executivo, função essa determinada por Lei Municipal. Outrossim, atua em todos os processos do contencioso civil (ação de cobrança (salvo execuções fiscais), ação de medicamentos, reparação civil, mandados de segurança, improbidades administrativas, etc, cabendo consignar também que atua em atendimento ao público, inclusive auxiliando nos processos de execução fiscal. Há que se consignar, que o regime celetista é o adotado para regulamentação da relação de emprego entre os funcionários públicos do município de Pindorama/SP, o que dá ensejo ao grande número de reclamações trabalhistas, que atualmente perfaz o montante de 245 (duzentos e quarenta e cinco) processos trabalhistas. Além de todo o expediente já citado, resta ainda o expediente relativo ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que demanda aprofundado conhecimento específico sobre o tema. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem o entendimento assentado no sentido de que: "A contratação de serviços de advogado por inexigibilidade de licitação está expressamente prevista na Lei n. 8.666/93, art. 25, II c.c. art. 13, V" (Resp n. 1.285.378/MG, 2ª Turma, rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 13.03.2012). Daí porque não cabe ao requerente reprovar de modo generalizado e indistinto, a decisão administrativa de promover a terceirização dos serviços advocatícios, que busca por meio dos profissionais contratados, apenas respaldar juridicamente a municipalidade nos casos específicos, sendo o mesmo entendimento do E. TJSP. Por fim, em relação a contratação de Assessorias Jurídicas, insta trazer à baila o recente entendimento do STF na ADC. Diz o Relator Barroso: "São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, desde de que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado". Afirma que não é possível vedar-se a contratação de escritórios de advocacia, ante a recente manifestação da nossa mais alta corte que, inclusive reconhece a possibilidade de dispensa de contratação em determinados casos. No tocante a autorização legal Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos para representar o município em juízo, o representante do Ministério

Público menciona faticamente que: “Visualizada a legislação local que trata da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e do cargo de Secretário Municipal dos Assuntos Jurídicos, Lei n. 2.104/2013, nos artigos 21 e 22 (Doc. 02) e Lei Complementar 2273/2017, no Anexo I, conclui-se que não há qualquer norma municipal autorizando, determinando, ordenando ou conferindo ao Secretário a atribuição de procuradoria do Município, ou seja, o Secretário Jurídico, em Pindorama, legalmente, não está autorizado a representar judicialmente o Município, o que, segundo a legislação municipal, que está correta e condizente com o melhor direito constitucional, somente os Procuradores e o Procurador Geral teriam referida atribuição, seja pelo teor da Lei n. 2.104/2013, artigos 21 e 22, seja pela Lei 2.410/2021 (Docs. 04), artigo 1º, funções Procurador Geral e Procurador Jurídico, que cuida das atribuições desses cargos, o que, anteriormente, era tratado no Decreto n. 2203/2014, o que foi corrigido pela lei de 2021 já mencionada. A Lei Complementar Municipal 2104 de 18 de abril de 2013, Seção VII, em seu art. 21 (anexo), menciona taxativamente as competências e atribuições da Secretaria de Assuntos Jurídicos, ao contrário do mencionado pelo Ministério Público, existe lei municipal vigente que autoriza o Secretário Municipal De Assuntos Jurídicos a representar o município judicialmente e extrajudicialmente, propor ação civil ou de inconstitucionalidade de lei, desde que determinado pelo Prefeito, promover a cobrança judicial da dívida ativa. Mais adiante, o art. 22 também da lei Complementar Municipal 2104 de 18 de abril de 2013, Já o parágrafo único do art. 22, trata da equiparação dos cargos de procurador geral e Secretário de Assuntos Jurídicos, frisando que, para todos fins de direito, o cargo de Procurador Geral do Município fica equiparado ao cargo de Secretário Municipal dos Assuntos Jurídicos, em caso de vacância deste. A norma municipal, como se denota, não confere atribuição de procuradoria do município a Secretaria de Assuntos Jurídicos, o art. 21 da lei Complementar Municipal 2104 de 18 de abril de 2013, é bem claro, e especifica todas as competências e atribuições do Secretário de Assuntos Jurídicos, e dentre as atribuições, está a autorização para representar o município em juízo. Discorreu sobre as atribuições do Procurador Jurídico Municipal tanto as atribuições do Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, quanto as atribuições do Procurador Jurídico do Município, guardam semelhança, no entanto, não ocorre usurpação de competência entre os cargos, pois ambos possuem atribuições detalhadas em leis municipais distintas, e ambos estão aptos a representar o município em juízo. Ademais, cumpre informar que é requisito indispensável ao ocupante do cargo de Secretário Municipal de Assuntos, a aprovação no Exame da OAB, pois a Lei Complementar Municipal 2273 de 19 de Dezembro de 2017 que dispõe sobre a criação do quadro dos cargos das Secretarias Municipais, e passam a integrar a lei Complementar Municipal 2104 de 18 de abril de 2013. Por fim, menciona no anexo I, os requisitos (Ensino Superior e OAB) para ocupação do Cargo de Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, isto é, para exercício da função de Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, é indispensável a graduação no curso de direito, bem como a habilitação como profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Muito embora não se atribua a nomenclatura de Procurador, resta claro que o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, de certa forma, atua como advogado público, seja defendendo os interesses do município judicialmente, ou até mesmo atuando na esfera administrativa, emitindo pareceres, assessorando juridicamente as demais Secretarias Municipais, e suprimindo juridicamente todo o expediente administrativo. Pela corrente defendida pelo representante do Parquet, o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos estaria também impedido de atuar juridicamente nas questões administrativas, tendo em vista que também, cabe ao procurador jurídico atuar no expediente administrativo, conforme descrito em suas atribuições. Aliás, é pacífico o entendimento do TCE/SP que os honorários de sucumbência são devidos aos Secretários Jurídicos, consoante decisão proferida no TC 800.223/299/095 e TC 800298/199/086, entendeu-se que “A percepção de verba honorária proveniente de sucumbência pelo Secretário Municipal de Justiça não comporta censura, haja vista sua natureza indenizatória tão apropriadamente explanada pela defesa. Desta forma, viável o recebimento do subsídio e da verba honorária. No que tange sobre a legalidade do secretário jurídico receber os honorários de sucumbência, é

importante registrar, que, com o advento da chamada reforma administrativa, promovida pela Emenda Constitucional nº 19/98, passaram a ser enquadrados como agentes políticos, remunerados exclusivamente por subsídios, consoante previsto no art. 39, §4º da CF/88. A fixação desses subsídios é realizada por lei de iniciativa da Câmara de Vereadores, segundo determina o inciso V do art. 29 da Carta Magna. O art. 39, § 4º, da CF/88, estabelece que estão excluídos dos subsídios os acréscimos de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de gratificação ou outra espécie remuneratória. Diferentemente do que ocorre com os adicionais ou gratificações, os honorários de sucumbência não são considerados como espécie remuneratória. Configuram-se um direito consagrado na Lei Federal nº 8.906/94, que, desde que previsto em lei municipal o rateio dos valores entre os advogados públicos, é plenamente legal que o Secretário Jurídico também receba a parcela correspondente, visto que, para exercício dessa função, é indispensável a sua habilitação como profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O que não se pode negar, é que muito embora os dois órgãos tratem de assuntos jurídicos de natureza administrativa e judicial, inexistente unicidade entre a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e a Procuradoria Jurídica do Município. Pois de igual forma, tanto a Procuradoria, como a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos possuem capacidade postulatória, isto é, tanto o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, quanto o Procurador Jurídico do Município, possuem atribuições jurídico administrativas e judiciais determinadas em lei municipal. Antes que se diga que as atribuições do Secretário Municipal de Assuntos jurídicos são da Procuradoria Jurídica do Município, derradeiramente resta consignar que as atribuições Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos estão previstas na Lei Complementar Municipal 2104 de 18 de abril de 2013, que em seu art. 21, nos incisos III, IV e V, autoriza o Secretário Municipal de Assuntos jurídicos, a representar a municipalidade em juízo, e as atribuições do Procurador Jurídico Municipal estão descritas na Lei Complementar Municipal 2410 de 22 de março de 2021. Pugnou pela improcedência do pedidos da inicial, protestou pela produção de provas e instruiu a constestação com documentos (fls. 304/515).

Houve réplica a fls. 518.

O Ministério Público do Estado de São Paulo pugnou pelo julgamento antecipado e instado a manifestar interesse em outras provas o Município réu se manifestou (fls. 520/521 e 529/532).

É o relatório.

DECIDO.

Julgo antecipadamente a lide, nos termos dos artigos art. 371 e 355, inc. I do Código de Processo Civil/2015, considerando que, embora a questão seja de direito e de fato, prescinde da produção de outras provas, estando o feito suficientemente instruído.

“PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE MAIS PROVAS - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE AFASTADA - PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da apelante não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato a nulidade de cerceamento de defesa ante a não realização da prova testemunhal, pericial ou depoimento pessoal. (...).” (TJSP, Apel. 1039171-14.2018.8.26.0002, Rel. Paulo Ayrosa, j. 19.11.2019).

Não há preliminares a apreciar.

No mérito, o Ministério Público do Estado de São Paulo requer a condenação do Município de Pindorama à obrigação de fazer consistente em cumprir sua própria legislação, passando toda a Procuradoria do Município, serviços jurídicos judiciais e extrajudiciais, aos Procuradores, servidores públicos concursados e efetivos, bem como à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de passar serviços jurídicos, representações processuais e trabalhos típicos da Procuradoria, previstos nos artigos 21 e 22, da Lei Complementar n. 2104/2013, ao Secretário

Jurídico, sob pena de multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por processo no qual o Secretário Jurídico oficie ou participe representando o Município.

São fatos incontroversos que o Município de Pindorama conta com apenas um Procurador Municipal concursado, que o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos exerce atribuições do cargo de Procurador do Município de Pindorama, representando judicialmente o Município em diversos feitos e que o Município réu contratou escritórios de advocacia para lhe prestar serviços.

Resta apreciar se esses fatos incontroversos violam a legislação pertinente.

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, que não configura irregularidade a contratação pelo Município de escritório de advocacia - ou advogados- quando o seu quadro de Procuradores é insuficiente para a eficaz defesa dos seus interesses nas esferas administrativa, judicial e extrajudicial, sendo possível que essa contratação ocorra ser licitação, em casos autorizados pela lei, sempre observado que o valor da contratação não pode ser exorbitante.

O entendimento do E. TJSP:

"Apelação Cível - Ação Civil Pública - Improbidade administrativa - Contratação de escritório de advocacia pela Municipalidade - Suposta violação dos artigos 10, caput e incisos IX, XI e XII, e 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92 - Não ocorrência - Acervo probatório não demonstra prejuízo ao erário ou ofensa aos princípios que regem da Administração Pública - Contratação precedida de regular procedimento licitatório - Ausência de prova de que o Município possuísse Procuradores em número suficiente e aptos à defesa de seus interesses na seara do Direito Público - Não comprovação, ademais, de que a contratação se deu por valor superior ao de mercado - Serviços efetivamente prestados - Ausência de comprovação do elemento subjetivo dolo/culpa a caracterizar o ato como ímprobo - Provimento dos recursos para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente a ação" (TJSP; Apelação Cível 1001081-31.2019.8.26.0315; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Laranjal Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/09/2021; Data de Registro: 28/09/2021).

"RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - REEXAME NECESSÁRIO - Ação popular - Alegação do autor de que a requerida Elaine Alvares Silveira Rocha, enquanto prefeita do município de Indaiaporã-SP, contratou a sociedade de advogados "Bruno César Rosselli Medri" para a execução das atividades regulares de advogados públicos. Alega, ainda, que o serviço de assessoria jurídica do município deve ser realizado por advogado concursado. Sustenta que o valor do contrato é incompatível com o praticado pelo mercado - Pretensão da suspensão liminar do contrato, a decretação de indisponibilidade de bens dos requeridos, e, ao final, a declaração de nulidade do contrato em questão - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor - Reexame necessário. O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.156.016 AgR/SP, pacificou o entendimento de que os municípios não estão obrigados a instituírem procuradorias municipais, sendo lícita a contratação de escritórios de advocacia para a realização do serviço genérico de assessoria jurídica - Ademais, o Município de Indaiaporã está instituindo procuradoria, tendo, inclusive, editado a Lei Complementar nº 056, de 1 de julho de 2019 (fls. 422), que criou os cargos públicos respectivos - Tendo o ente público optado por se organizar por meio de procuradoria própria, não há que se falar em não obrigatoriedade de observância da própria legislação municipal enquanto ela estiver em vigor - A mencionada norma foi editada antes da propositura da ação popular, só não tendo sido regularmente instituída a procuradoria municipal diante da impossibilidade da conclusão do concurso público. Deve a municipalidade observar os ditames legais para a contratação, dentre eles a realização de processo licitatório, não haverá ilicitude. No caso em escopo, diante do conjunto probatório produzido nos autos, ficou claro, que fora realizado regular processo licitatório (fls. 258/360), não havendo qualquer comprovação de fraude ou de que o preço cobrado pela sociedade de advogados "Bruno Cezar Rosselli Medri" tenha sido superior ao praticado pelo mercado. Valor da contratação não pareceu exorbitante (R\$ 6.600,00) mensais, quando comparado aos valores apresentados pelos demais licitantes que atenderam ao certame. Não há controvérsia quanto à efetiva prestação dos serviços contratados, tendo em vista que os sócios que compõe o escritório de advocacia atuaram em

diversas ações representando os interesses do Município de Indaiatuba/SP. Por fim, o contrato firmado era regular, não havendo demonstração da lesividade ou de violação à moralidade administrativa, a improcedência da ação era mesmo de rigor. A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer às fls. 616/622, manifestou-se pelo improvimento do recurso voluntário e do reexame necessário, mantendo-se a r. sentença de 1º grau. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença que julgou improcedente a ação, mantida – Recurso de apelação do autor, improvido - Reexame necessário, improvido” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000800-96.2019.8.26.0696; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Ouros - Vara Única; Data do Julgamento: 07/06/2021; Data de Registro: 07/06/2021).

Conforme reconhecido pelo Ministério Público, um único Procurador Municipal não é suficiente para a análise das milhares de demandas enfrentadas pela Municipalidade de Indaiatuba, restando plausível a contratação de escritórios de advocacia para tal mister, observado que nesse feito não se imputa ato de improbidade administrativa pela contratação daqueles profissionais ao longo dos anos.

Não há obrigação da Municipalidade em completar o quadro de Procuradores Municipais, ficando no campo da discricionariedade a abertura de concurso para tal fim, à semelhança do entendimento consolidado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, TEMA 784, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 873.311/PI de relatoria do Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, ao analisar a discricionariedade do Município quanto ao provimento de cargos : "(...) é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inoportunidade da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato".

Portanto, a Administração Pública tem discricionariedade, podendo escolher qual será a forma de gerir sua área jurídica, seja contratando advogados/escritórios de advocacia, por licitação ou com a sua dispensa nos termos do art. 25, II c.c. art. 13, V da Lei 8.666/93, seja criando ou completando os cargos nas procuradorias municipais.

A atuação do Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos para representar judicialmente o Município réu encontra respaldo na Lei Complementar Municipal 2104/2013 (fls. 348/350), que estabeleceu as competências daquele secretário, esclarecendo que a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos compreende Procuradoria do Município, estando para todos fins de direito, o cargo de Procurador Geral do Município equiparado ao cargo de Secretário Municipal dos Assuntos Jurídico em caso de vacância deste.

Portanto, nenhuma irregularidade há na conduta da Municipalidade de Indaiatuba ou na



atuação do Secretário Jurídico na defesa da Municipalidade nas esferas administrativa, judicial e extrajudicial, posto que autorizado pela lei municipal, cargo equiparado ao de Procurador do Município, não havendo que se falar em desvio de função ou usurpação da competência da Procuradoria do Município, observado que essa é parte da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (fls. 348/350). Desta feita, não cabe acolher o pedido do Ministério Público para “condenar o Município de Pindorama à obrigação de fazer consistente em cumprir sua própria legislação, passando toda a Procuradoria do Município, serviços jurídicos judiciais e extrajudiciais, aos Procuradores, servidores públicos concursados e efetivos, bem como à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de passar serviços jurídicos, representações processuais e trabalhos típicos da Procuradoria, previstos nos artigos 21 e 22, da Lei Complementar n. 2104/2013, ao Secretário Jurídico, sob pena de multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por processo no qual o Secretário Jurídico officie ou participe representando o Município”, posto que o momento para abertura de concurso para Procurador encontra-se na esfera da discricionariedade da Municipalidade e nenhuma irregularidade há no exercício da defesa dos interesses do Município por parte do Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos.

São esses os fundamentos jurídicos e fáticos, concretamente aplicados no caso, suficientes ao julgamento da presente lide, considerando que outros argumentos deduzidos pelas partes no processo, referem-se a pontos irrelevantes ao deslinde da causa, incapazes de infirmarem a conclusão adotada na presente sentença, cumprindo-se os termos do artigo 489, inciso IV, do CPC/2015, “para que possa ser considerada fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes, que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a decisão” (Comentários ao Código de Processo Civil – novo CPC – Lei 13.105/2015, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2015, 1ª edição, ed. RT, p. 1155).

Por fim, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Isto Posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas, despesas processuais ou verba honorária.

P.I., intimando-se a Fazenda Pública, via portal eletrônico.

Catanduva, 15 de março de 2022.

MARIA CLARA SCHMIDT DE FREITAS

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA